



民事訴訟法

「手続保障」

学習院大学教授
長谷部由起子
HASEBE Yukiko



はじめに

「手続保障」については、近年多くの教科書で触れられている。法学部で民事訴訟法を勉強したことがある人には、なじみのある概念であろう。そうであるだけに、内容を深く理解せずに使っていることはないだろうか¹⁾。

たしかに、「手続保障」は民事訴訟法における重要な概念の1つではある。しかし、「当事者」、「訴えの利益」、「既判力」などのドイツ法に淵源のある概念に比べれば、歴史は浅い。「手続保障」という言葉が教科書で用いられたのは、1974年に刊行された新堂幸司『民事訴訟法』が最初だといわれている²⁾。相対的に新しく、かつ、外国法の直接的な影響を受けることなくわが国独自の発展を遂げた概念であるけれども、だからといって、他の概念よりも平明で理解しやすい議論が展開されてきたというわけではない。むしろ、短い期間に多様な見解が提唱された結果、議論は複雑になり、全体像が見えにくくなっているように思われる。

手続保障をめぐるこれまでの議論を振り返れば、人が手続の主体（当事者）たる地位につく

ことによって保障されるべき権利（当事者権）に着眼することから始まり³⁾、当事者に対して十分な手続保障が与えられたことが、不利な裁判にも当事者は従わなければならないことを正当化するという議論へと進んできた。当事者以外の者（訴訟担当における被担当者、口頭弁論終結後の承継人）に対する既判力の拡張の根拠としても、手続保障の概念が用いられるようになってきている⁴⁾。こうして議論のルートが開拓されてきたならば、それに沿って「手続保障」を論じていくことが、堅実で生産的な議論を可能にするように思われる。すなわち、個別の問題に関して当事者に手続保障があったか否かを論ずるにあたっては、まず、当該事案では当事者にどのような手続上の権利が保障されるべきか、そうした保障がなかったのはどのような要因に基づくものかを分析することから始める。そして、当事者に対する権利の保障を欠いたまま、その当事者に不利な扱いをすることがはたして正当化されるのかを検討していくことになる。

このような考え方に基づいて、判例にあらわれた問題にアプローチしてみよう。なお、以下で引用する条文は、断りのない限り、令和4年改正後の民事訴訟法の条文である。



口頭弁論の再開

——攻撃防御方法を提出する機会の保障

1. 弁論を再開せずに判決をすることが違法とされる場合

裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したとき、口頭弁論を終結して終局判決をすることができる（243条1項）。いったん終結した弁論を再開することもできるが（153条）、その要件は法定されていない。判例・通説によれば、弁論を再開するか否かは裁判所の裁量的判断に委ねられており、当事者に弁論の再開を申し立てる権利はないとされている⁵⁾。

もっとも、裁判所の裁量にも限界はあり、弁論を再開しないことが違法とされる場合もある。この問題について、最判昭和56・9・24

1) 山本和彦「手続保障」法教415号（2015年）35頁は、「近年、一種のマジックワードとして手続保障を用いる（あるいは濫用する）学生が多い」としている。

2) 伊藤真「学説史からみた手続保障」新堂幸司編著『特別講義民事訴訟法』（有斐閣、1988年〔初出1982年〕57頁注1）。

3) 当事者権の概念を提唱したのは、山本戸克己「訴訟における当事者権」同『民事訴訟理論の基礎的研究』（有斐閣、1961年〔初出1959年〕）59頁以下であった。

4) その後も、「手続保障の第三の波」論や形式的手続保障と実質的手続保障を対置させる議論がなされているが、これらに対する評価は定まっていない。

(民集35巻6号1088頁)〔民事訴訟法判例百選〔第5版〕41事件〕は以下のように述べて、弁論を再開しなかった原審の措置を違法であるとした。

「〔弁論を再開するか否かについての裁判所の〕裁量権も絶対無制限のものではなく、弁論を再開して当事者に更に攻撃防禦の方法を提出する機会を与えることが明らかに民事訴訟における手続的正義の要求するところであると認められるような特段の事由がある場合には、裁判所は弁論を再開すべきものであり、これをしないのでそのまま判決をするのは違法であることを免れない」。

2. 本件の事実関係とそれに対する 本判決の判示

(1) 本件の事実の概要は、以下のとおりである。

A(原告・被控訴人)は、Y(被告・控訴人・上诉人)に対して、A所有の不動産(本件不動産)につきYのためにされた所有権移転登記、抵当権設定登記等はいずれも登記原因を欠き、実体上の権利関係に適合しないと主張して、これらの登記の抹消登記手続を求める訴えを提起した。これに対してYは、以下の理由により本件各登記は実体関係に符合する有効なものであると主張した。

(i) 本件各登記は、AまたはAより一切の権限を与えられていたX(Aの養子・被上诉人)から代理権を授与されたBが、Yとの間で、本件不動産につき締結した譲渡担保設定契約、抵当権設定契約、代物弁済予約契約を原因とするものである。

(ii) かりに、Bが上記各契約の締結について代理権を有しなかったとしても、AまたはAの代理人であるXは、BにAの実印および本件不動産の権利証を交付することにより、Bに代理権を与えた旨を表示した。

(iii) かりに、(i)(ii)の事実が認められないとしても、Aの代理人であるXは、Bに対し、A所有の土地をC株式会社に売り渡す契約の締結およびその所有権移転登記手続を委任していたところ、Bがその権限を超えて(i)の各契約を締

結したものであるが、YにはBに権限があると信ずる正当な理由があった。

第一審はAの請求を認容し、これに対してYが控訴した。

原審の口頭弁論終結前の昭和54年7月15日に、Aが死亡したが、訴訟代理人がいたため訴訟手続は中断せず、かつ、訴訟承継の手続もとられなかった⁶⁾。原審は、Aを当事者としたまま、同年10月30日に弁論を終結し、判決言渡期日を同年12月25日と指定した。

ところがYは、同年11月7日に、Aの死亡を知ったとして、口頭弁論再開申請書と題する書面を原審に提出し、同月14日には、Aが死亡したことを証する戸籍謄本を添付した口頭弁論再開申立書およびXはAの死亡により同人の権利義務一切を承継したから自己ないしBの行為につき責任を負うべきである旨を記載した準備書面を提出した。

しかし原審は、口頭弁論を再開せず、Yの(i)から(iii)の抗弁をすべて排斥して、Yの控訴を棄却した。これに対してYが上告した。

(2) 本判決は、本件においては以下の事情が認められるとして、原審としては、いったん弁論を終結した場合であっても弁論を再開して、Yに対してYが原審の口頭弁論終結前に主張することができなかった事実を主張する機会を与え、これについて審理を遂げる義務がある、とした。

① Yは、Aが原審の口頭弁論終結前に死亡したことを知らず、かつ、知らなかったことにつき責めに帰すべき事由がないことがうかがわれること。

② Yが弁論再開を申請した理由は、Aが死亡しXがAを相続したことにより、Yが原審において主張した前記(ii)の表見代理における少なくとも一部についての授權の表示および前記(iii)の表見代理における基本代理権が存在することになるというべきであるから、Yは原審に対し、上記事実に基づいてBの無権代理行為に関する民法109条ないし110条の表見代理の成否について更に審理判断を求める必要があるというものであり、このYの主張は、本件におい

5) 最判昭和23・4・17民集2巻4号104頁、最判昭和23・11・25民集2巻12号422頁、最判昭和38・8・30集民67号361頁、最判昭和45・5・21集民99号187頁、伊藤真『民事訴訟法〔第7版〕』(有斐閣、2020年)300頁、兼子一原著『条解民事訴訟法〔第2版〕』(弘文堂、

2011年)932頁〔新堂幸司=上原敏夫〕、秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅲ〔第2版〕』(日本評論社、2018年)354頁など。

6) 以上が意味するところについては、後述3(2)を参照。

て判決の結果に影響を及ぼす可能性のある重要な攻撃防禦方法であること。

③ Yが②の主張を提出する機会を与えられないまま、Y敗訴の判決がされ、それが確定した場合には、その既判力により、Yは、後訴において上記事実を主張してその判断を争うことができなくなること。

3. 本判決の考え方

(1) 本判決は、原審には弁論を再開する義務があることの根拠として「民事訴訟における手続的正義の要求」を挙げた。この点については、手続保障を重視する当時の学説に照応した新しい方向を示すものとする見解⁷⁾とそのようにいうことは無理だとする見解⁸⁾とがある。しかし、本判決が当事者に対する手続保障に配慮していることについては、争いはない。本判決の意義は、当事者に対する手続保障の観点から、裁判所が弁論の再開を義務付けられる場合があることを明らかにし、その判断基準を示したところにあるというのが、一般的な理解である。

それでは本判決は、Yにはどのような手続上の権利が保障されるべきだと考えていたのだろうか。

本判決が指摘する前記2(2)②の事情からは、Yには、判決の結果に影響を及ぼす可能性のある重要な攻撃防禦方法を提出する権利があると考えていたことがうかがわれる。しかし当事者は、いつまでも攻撃防禦方法を提出することができるわけではない。

現行民事訴訟法の下では、攻撃防禦方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない(156条。適時提出主義)、当事者が故意または重大な過失によって時機に後れて提出した攻撃防禦方法は、そのために訴訟の完結が遅延すると認められれば、裁判所により却下される(157条1項)。本判決当時は、攻撃防禦方法は口頭弁論終結に至るまで提出できるとされていたが(旧民訴137条。随時提出主義)、時機に後れた攻撃防禦方法についての扱いは、現行法と同様であった(同法139条1項)。また、

本判決が前記2(2)③において指摘しているように、訴訟の基準時(事実審の口頭弁論終結時)までに提出することができた攻撃防禦方法を基準時後に提出して前訴判決の既判力ある判断を争うことはできない。このことは、基準時までに出しなかったことについての当事者の過失の有無を問わないとされている。

(2) 本件では、控訴審の口頭弁論がすでに終結されており、Yは攻撃防禦方法を提出する権利を行使することができない状態であった。しかし最高裁は、このままY敗訴の原判決を確定させるべきではない、と考えた。本判決の評釈は、この結論を導くうえで重要な要因として、YがAの死亡に基づく防禦方法を原審の口頭弁論終結前に主張しなかったことにつきYの責めに帰すべき事由がなかったこと(前記2(2)①)を指摘している⁹⁾。Yに帰責事由がないといえるのはなぜか、考えてみよう。

訴訟係属中に当事者が死亡した場合、訴訟物たる権利関係が一身専属的なものでない限り訴訟手続は中断し、相続人がいれば、この者が新たな当事者として訴訟手続を受継する(124条1項1号)。旧当事者から新当事者への変更は旧当事者の死亡と同時にに行われているが、この時点から新当事者が訴訟を進行することは期待できないので、いったん訴訟手続を中断し、新当事者の受継の申立てにより、手続を再開することになっている¹⁰⁾。しかし、旧当事者に訴訟代理人がいる場合には、訴訟手続は中断しない(同条2項)。訴訟代理人の訴訟代理権は、旧当事者の死亡によっても消滅せず(58条1項1号)、訴訟代理人は新当事者の代理人として訴訟を進行すると解されているため¹¹⁾、訴訟手続を続行しても新当事者の利益は損なわれないからである。本件でも、Aには訴訟代理人がいたため訴訟手続は中断しなかった。また、Aの訴訟代理人がA死亡の事実を直ちに控訴裁判所に届け出ていれば、裁判所は、Aの相続人Xを新当事者として扱ったであろうが、本件ではそうした手続(訴訟承継)もとられていなかった。そのためにYは、原審の口頭弁論終結前

7) 太田勝造・法協100巻1号(1983年)210-211頁。

8) 新谷勝・民事訴訟法判例百選I〔新法対応補正版〕(1998年)183頁。

9) 山本戸克己・法時54巻3号(1982年)153頁、佐上善和・昭和56年度重判解136頁、太田・前掲注7)215頁。

10) これは、当事者双方に手続関与の機会を平等に与えなければならないという双方審尋主義の要請に基づくものである。新当事者が手続に関与できる状態になるまで訴訟手続を再開しないという規律により、新当事者に対する手続保障が図られているといえる。

11) 最判昭和33・9・19民集12巻13号2062頁。

にはAの死亡を知らなかったのであり、知らなかったことにYの責めに帰すべき事由もなかったと考えられる¹²⁾。



補充送達の効力と再審事由 ——当事者に対する手続関与の機会の保障

1. 訴状・判決の送達を受ける当事者の権利

当事者が訴訟手続に関与し、攻撃防御方法を提出する権利を行使するためには、みずから当事者とする訴訟が係属していることを知り、口頭弁論がいつ、どこで開かれるのかを知る必要がある。また、不利益な判決を受けた当事者がその判決に対して上訴するためには、判決の内容を知る必要がある。被告が、訴状の送達を受ける権利(138条1項)を保障され、原告および被告が、期日の呼出しを送達その他の方法で受ける権利(94条)および判決の送達を受ける権利(255条)を保障されているのは、当事者に訴訟手続に関与する機会を保障する必要があるためである。送達がどのような方法で行われ、どのような効果を持つかは、当事者の手続保障との関係で重要な意義を有していることになる。

2. 送達の方法・効果

送達は、原則として交付送達の方法で行われる。これは、訴状その他の送達すべき書類を送達を受けるべき者(受送達者)に現実 to 交付する送達方法である(102条の2)。送達場所は、原則として受送達者の住所、居所、営業所または事務所であるが(103条1項本文)、これらの場所が知れないとき、またはこれらの場所において送達をするのに支障があるときは、受送達者の就業場所においてすることができる(同条2項)。

就業場所以外の送達場所において送達実施機関が受送達者に出会わないときは、使用人その他の従業者または同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる(106条1項前段)。就業場所において受送達者に出会わない場合におい

て、雇用主またはその法定代理人もしくは使用人その他の従業者で、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときにも、これらの者に書類を交付することができる(同条2項)。この送達方法は、補充送達と呼ばれている。

交付送達の効力は、書類が受送達者に交付されたときに生じる。補充送達の場合は、書類が同居者等に交付されたときに、受送達者に対する送達の効力が生じる。書類を受領した同居者等は、書類が受送達者にとって重要なものであることを理解しているので、通常は書類を受送達者に交付する。しかし、同居者等が受送達者と対立関係にあるために、受送達者に書類を交付しないこともある。このような場合にも、補充送達は有効だろうか。有効だとすると、訴状や判決が送達された事実を知らなかったために、当事者としての権利を行使することができず、敗訴判決が確定してしまった受送達者に対しては、どのような救済が与えられるのだろうか。以上の問題を扱ったのが、最決平成19・3・20(民集61巻2号586頁)[前掲百選5版40事件]である。

3. 最決平成19・3・20の事案

本件は、XがYに対して提起した再審の訴え(本訴)に関するものである。再審の訴えの対象となったのは、Yが、Aを主債務者とし、Xを連帯保証人として両名に対して提起した貸金返還請求訴訟(前訴)におけるY勝訴の確定判決であり、この判決がされるまでには、以下の経緯があった。

AはXの義父であり、Xと同居していたため、Xに対する訴状および第一回口頭弁論期日への呼出状の送達は、Aに書類を交付する補充送達の方法で行われた。しかし、Aは書類をXに交付しなかった。それは、本訴におけるXの主張によれば、Xが連帯保証人になったのは、Xの意思に基づくものではなく、AがXに無断でXの印章を持ち出して連帯保証契約を締結したことによる。すなわちAは、Xを受送達者とする訴状等をXに交付すれば上記の事情をXに知られてしまうので、訴状等を

12) Yが新聞の死亡記事を見たり、Aに近い人の話を聞いたりすれば、Aの死亡を知る可能性はあったかもしれない。しかし、それをしなかったからといって、Yの責め

に帰すべき事由があったとはいえない。そもそもYには、訴訟係属中にAが死亡したか否かを調査すべき訴訟上の義務はないのである。

Xに交付しないことに利益を有していた。この点において、AとXの間には事実上の利害関係の対立があったといえる¹³⁾。

訴状等を交付されていないXは、第一回口頭弁論に欠席し、答弁書等も提出しなかったため、YのXに対する請求を認容する判決（第一審判決）が言い渡された。この判決については、判決書に代わる調書（254条2項）が書留郵便等に付する送達（107条）の方法でXに送達され、送達の効力が生じているが¹⁴⁾、実際にはX不在のため書類はXに交付されなかった。Y勝訴の判決がされたことを知らないXからの控訴はなく、この判決が確定した。

Xは、Xに対する訴状等の補充送達は無効であり、Xに訴訟に関与する機会が与えられないまま前訴判決がされたのであるから、前訴判決には338条1項3号の再審事由（以下「3号再審事由」という）があると主張した。

4. 本決定の考え方

本訴の第一審および原審は、Xに対する訴状等の送達は補充送達として有効であり、3号再審事由は認められないとして、Xの再審請求を棄却すべきであるとした。これに対して本決定は、以下のように述べて、Xに対する訴状等の送達は補充送達として有効であるけれども、3号再審事由が認められるとした。

「本件訴状等の送達が補充送達として有効であるからといって、直ちに民訴法338条1項3号の再審事由の存在が否定されることにはならない。同事由の存否は、当事者に保障されるべき手続関与の機会が与えられていたか否かの観点から改めて判断されなければならない。」

「受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等と受送達者との間に、その訴訟に関

して事実上の利害関係の対立があるため、同居者等から受送達者に対して訴訟関係書類が速やかに交付されることを期待することができない場合において、実際にもその交付がされなかったときは、受送達者は、その訴訟手続に関与する機会を与えられたことにならないというべきである。」

3号再審事由は、確定判決が無権代理人の訴訟行為に基づいてなされた場合を想定したものであるが、判例（大判昭和10・10・28民集14巻1785頁〔前掲百選5版5事件〕）は、氏名冒用訴訟において他人に名前を使われた本人が再審の訴えを提起した場合にも3号再審事由を認めている。下線を付した部分は、より一般的に、当事者とされた者が訴訟手続に関与する機会が与えられないまま判決が言い渡され確定した場合には、その者に3号再審事由が認められることを明らかにしたものである。判決の成立過程において当事者に対する手続保障を欠いたならば、当該判決の既判力を当事者に及ぼすことは正当化されないことを言明したものとえよう。

Ⅳ 結び

「手続保障がない当事者に判決の効力を及ぼしてはならない」という命題は、いまでは「裁判は適正・公平でなければならない」という命題と同様に、疑う余地のないものであろう。しかし、たんに手続保障があるとかないとかいうだけでは意味がない。当事者は訴訟手続においてどのような権利を保障されなければならないか、現行民事訴訟法の解釈として、当事者にはどのような権利が保障されているのかを、具体的な事案に即して論証する必要がある。本稿での検討が読者の参考になれば幸いである。

（はせば・ゆきこ）

13) XA間に事実上の利害関係の対立があるにとどまらず、法律上の利害関係の対立がある場合としては、XとAが訴訟の対立当事者である場合があるとされている。

14) 送達が書留郵便等に付する送達によって行われた場合には、送達の効力は発送の時に生じ（107条3項）、受送達者が実際に書類を受け取ったか否かを問わない。